

刑法
No150

H20-5

(配点：3)

月 日

月 日

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲と乙が、丙に対して同時に1発ずつけん銃を発射し、そのうち1発は丙の頭部をかすめたものの命中せず、もう1発が丙の頭部に命中し、それにより丙は死亡した。丙の頭部に命中した銃弾が甲乙いずれのけん銃から発射されたものであるかは判明しなかった。

【記述】

ア. 甲と乙が、共同して丙を殺害する意思をもってけん銃を発射した場合、甲及び乙には殺人既遂罪の共同正犯は成立せず、殺人未遂罪の共同正犯が成立する。

イ. 甲は、乙がけん銃を発射することを知り、乙と共同して丙を殺害する意思で自らもけん銃を発射したが、乙は、甲がけん銃を発射することも丙を殺害しようとしていることも知らないまま、自分一人で丙を殺害する意思をもってけん銃を発射した場合、甲には殺人罪の共同正犯が成立し、乙には殺人未遂罪の単独犯が成立する。

ウ. 甲と乙は、互いに何ら意思の連絡なく、それぞれ丙を殺害する意思をもってけん銃を発射した場合、甲乙にはそれぞれ殺人未遂罪の単独犯が成立する。

エ. 甲は、丙を殺害する意思をもって、乙に対し、「あれはマネキン人形だ。一緒に射撃しよう。」とうそを言ったところ、乙はこれを鵜呑みにしてよく確認もせず丙をマネキン人形と誤信し、甲と共にけん銃を発射した場合、甲には殺人罪の単独犯が成立し、乙には重過失致死罪の単独犯が成立する。

オ. 甲と乙が、共同して丙に傷害を負わせる意思をもってけん銃を発射した場合、甲及び乙には傷害致死罪の共同正犯が成立する。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ オ

No150

H20-5

共同正犯の主観的要件

正解

5

正答率

93%

ア 誤っている

共同正犯（60条）においては、犯罪を実行するための行為の一部を行えば、これによって生じた犯罪結果の全部について責任を負うことになる（一部実行の全部責任の原則）。甲と乙は共同して丙を殺害する意思をもってけん銃を発射しており、共同正犯関係に立つから、丙の死の結果に対し共同して責任を負う（殺人既遂罪の共同正犯）。

イ 誤っている

甲は乙と共同して丙を殺害する意思があるが、乙は甲が共同して丙を殺害をしようとしていることにつき認識がないので、片面的共同正犯となるが、判例は、共同正犯の成立を否定している（大判大 11. 2. 25）。共同正犯において一部実行の全部責任の原則を認める趣旨は、共同者各自が相互に他人の行為を利用し補充しあって構成要件の事実を実現することにあるから、共同実行の意思が各共同者に認められない限り共同正犯が成立することはないからである。

ウ 正しい

最判昭 23.12.14。判例は、共同正犯が成立するためには、行為者双方の間に意思連絡のあることが必要であるとしている。共同行為者間に相互利用・補充関係が認められない場合、一部実行の全部責任の原則は妥当せず、同時犯が成立するに過ぎないからである。よって、甲乙に共同正犯は成立せず、別々に単独犯が成立する。丙の頭部に命中した銃弾が甲乙のいずれのけん銃から発射されたものであるのか不明である以上、甲乙の行為と丙の死の結果との間の因果関係を認めることはできず、甲乙はそれぞれ殺人未遂罪の単独犯となる。

エ 誤っている

単独犯として乙に罪責を問う場合、乙の行為と丙の死の結果との間に因果関係が認められることが必要である。本記述において乙のけん銃から発射された銃弾によって死亡した事実が判明しない以上、乙の行為と丙の死の結果との間の因果関係を認めることはできない。そのため、乙に死の結果を帰責することはできない。

オ 正しい

最判昭 26.3.27（百選Ⅰ〔第7版〕79事件）。甲乙は丙に傷害を負わせる意思で死の結果を招来させているので、死の結果に対しては共同意思が認められないので、結果的加重犯の共同正犯が成立し得るかが問題となる。判例は、基本となる犯罪に対する共同正犯が成立する場合には、結果的加重犯における加重部分についても共同正犯の成立を認める。結果的加重犯は、基本となる犯罪が一定の重い結果を発生する危険を含むために独立の犯罪とされたものであるから、結果的加重犯の基本となる犯罪の共同実行者には、通常、重い結果の発生について具体的予見可能性が認められ、各自の重い結果を回避すべき共同の注意義務が課せられるからである。本問において甲乙は、共同して丙に傷害を負わせる意思で実行行為を行い、死の結果を招来している。よって、判例に従えば、結果的加重犯たる傷害致死罪（205条）の範囲で共同正犯が成立する。